

1500548-96.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Ao final, em caso de eventual condenação, manifestou-se acerca da dosimetria da pena, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Preliminarmente, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500548-96.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500548-96.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN ROBERTO DE SOUZA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

JEAN ROBERTO DE SOUZA e VITOR MOREIRA DE LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 12 de maio de 2022, às 14h40min, na Rua Açucenas, nº 239, Parque Brasil, nesta cidade e Comarca de Bragança Paulista, os acusados guardavam para a venda, fornecimento ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, 46 (trinta e um) pedras de crack e uma porção de maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma certa quantia em dinheiro (R\$ 5200 com Jean e R\$ 37,70 com Vítor).

Os acusados foram notificados (fls. 118/119) e apresentaram defesa prévia às fls. 130/131.

Após, a denúncia foi recebida em 07 de julho de 2022, às fls. 134/135. Habilitação da Defesa do acusado Jean, juntando documentos de fls. 146/151. Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns. Após, os réus foram interrogados (fls. 156/157). Nos termos do artigo 402 do CPP, foi deferido o prazo de 10 dias para a juntada de documentos pela Defesa. Documentos juntados às fls. 158/170. Manifestação do acusado Jean às fls. 177. Encerrada a instrução, os debates orais foram convertidos em memoriais, oportunidade em que o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, manifestando-se acerca da dosimetria da pena (fls. 178/184). A Defesa de Jean se manifestou a fls. 189/200. Requereu a improcedência da ação, absolvendo-se o acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. De forma subsidiária, manifestou-se acerca da dosimetria da pena, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A Defesa de Vitor se manifestou a fls. 207/227. Preliminarmente, se manifestou pela nulidade das provas, nos termos do artigo 157, §1º, do CPP (teoria dos frutos da árvore envenenada), absolvendo o acusado por insuficiência de provas, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP. De forma subsidiária, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Ao final, em caso de eventual condenação, manifestou-se acerca da dosimetria da pena, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade das provas. Os policiais realizaram a abordagem dos acusados após avistarem os réus adentrarem rapidamente em uma mercearia ao visualizarem a viatura. No mais, o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Nesse contexto, não se verifica nenhuma irregularidade, nos termos apontados pela Defesa, tanto é que foram localizados entorpecentes com os acusados, sendo descabido falar em ilicitude de provas. No mérito, a ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência a fls. 10/13, pelo auto de exibição e apreensão a fls. 16/17, pelo auto de constatação preliminar de fls. 18/19 e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 103/111), que apontou resultado positivo para maconha e cocaína nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião, bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria, por sua vez, restou comprovada. Na fase policial, Jean negou a prática delitiva. Relatou que foi até o supermercado comprar pão com manteiga e levou o valor de R\$ 50,00. Ao sair do local, foi abordado pelos policiais. Negou reconhecer as drogas. Sobre Vitor, disse que jogam bola juntos, mas não sabe muito sobre ele. Por fim, afirmou que já foi viciado em crack, mas hoje usa apenas cocaína (fls. 28). Vitor, por sua vez, durante o seu interrogatório policial negou a prática delitiva. Disse que foi tomar cerveja na mercearia e encontrou Jean, um conhecido do futebol. Disse que Jean estava comendo pão e o interrogado tomando cerveja quando foram abordados pelos policiais. Negou a propriedade das drogas. Relatou que estava apenas com o valor de R\$ 37,70, sendo que levou o valor de R\$ 55,00 e ingeriu 6 latas de cerveja Skol, de 300ml (fls. 29). Em juízo, Jean reiterou a negativa, negando a propriedade dos entorpecentes. Disse que possuía apenas a quantia de R\$ 52,00. Conhecia os policiais de outras abordagens, mas nunca foi levado preso. Não sabe dizer se os policiais teriam motivos para prejudicá-lo. Não conhece o Vitor, afirmando que já o viu de vista. Disse que é usuário. Entrou no mercado para comprar pão, quando foi abordado. Não entrou na mercearia junto com o Vitor. O local é ponto de tráfico e já comprou drogas no local. É usuário desde os 15 anos.

Vitor, por sua vez, disse que havia acabado de comprar a droga. Entrou na mercearia para comprar uma lata de cerveja, um maço de cigarros e um isqueiro, quando foi abordado pelos policiais. Disse que a droga não era para venda, mas para uso próprio, esclarecendo que chegou a ser internado em clínica de recuperação por duas vezes. Afirmou que estava dormindo na casa de uma tia, que reside na rua de baixo do local de sua abordagem. Não conhecia o Jean, afirmando que apenas o conhecia de vista. Não conhecia os policiais, relatando que nunca foi abordado por eles. Não sabe dizer se encontraram drogas com o Jean, já que cada um foi revistado de um lado. Foi voluntariamente internado nas clínicas para recuperação. É usuário de crack e maconha. Não possui passagens na Vara da Infância. Pagou o valor de R\$ 160,00 nos entorpecentes. Por fim, disse que consumiria toda a droga em dois dias. Paulo Roberto Panteleão Junior, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento, quando visualizam os dois indivíduos adentrarem em uma mercearia. Realizaram a abordagem de imediato, sendo o local conhecido pela venda de entorpecentes. No período da manhã já havia abordado os dois indivíduos, junto com outras pessoas, mas nada de ilícito fora localizado. Em outra ocasião já havia abordado o Jean. Esclareceu que a mercearia tem um espaço físico bem reduzido, razão pela qual os retiraram do interior do local e fizeram as buscas na rua. O depoente localizou com Jean entorpecentes e dinheiro, na região da genitália, e o seu parceiro localizou dinheiro e entorpecentes em uma bolsa que Vitor carregava a tira colo. A proprietária do estabelecimento afirmou que não viu nada. Disse que o seu parceiro fez uma varredura no estabelecimento, mas nada de ilícito foi encontrado. Recorda-se de ter encontrado 31 invólucros de crack e R\$ 52,00, em espécie. O Jean confirmou que estava vendendo entorpecentes. Não conhecia o Vitor. Não avistou nenhum ato de comércio das drogas. Não se recorda se o Vitor relatou sobre interações em clínica de recuperação. Não foram localizados outros objetos relacionados ao tráfico. Não havia denúncias sobre o Vitor. Sabe que o Jean já foi abordado por outros policiais.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Erick Roger Morandin Aparecido. Acrescentou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas, sendo que os acusados, ao avistarem a viatura, adentraram repentinamente na mercearia, razão pela qual fizeram a abordagem. Nas buscas pessoais, com ambos foram localizados crack, maconha e dinheiro. Recorda-se de ter revistado o Vitor, que carregava uma pochete. Localizou 15 pedras de crack, uma porção de maconha e R\$ 37,00 em dinheiro. Afirmou que o seu parceiro também localizou um saco plástico escondido na cueca, com pedras de crack e dinheiro. Na mercearia havia também a proprietária do local. As buscas foram realizadas na calçada. O Vitor não disse nada sobre as drogas localizadas. Já havia feito outras abordagens nos indivíduos, sendo que na parte da manhã, recorda-se de ter abordado o Jean. Já havia abordado o Vitor em outras ocasiões. Não presenciou atos de comércio de droga. Não se recorda se o Vitor estava consumindo cerveja. Não sabe dizer se o Vitor já foi internado em clínicas de recuperação.

Pela prova oral produzida, verifica-se que a autoria do crime de tráfico restou comprovada.

Inicialmente, anoto que quanto aos depoimentos dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção relativa de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela Defesa.

Ademais, nada indica que os policiais tenham criado alguma situação para acusar falsamente os acusados, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove a implantação de drogas.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita." (RTJ68/64).

E ainda:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando

prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (HC nº 74.608-SP/STF).

No caso dos autos, é certo que os policiais militares abordaram os réus em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, após fundada suspeita, já que os réus, ao avistarem a viatura, adentraram rapidamente em uma mercearia.

Durante a abordagem, foram localizados entorpecentes, sendo 31 pedras de crack, pesando aproximadamente 9g, 15 pedras de crack, pesando aproximadamente 3g, e uma porção de maconha, pesando 1,7g, além da quantia total de R\$ 89,70, tudo na posse dos acusados.

E, em que pesem as versões dos réus, suas alegações restaram isoladas das demais provas constantes dos autos, não havendo nos autos nenhuma prova testemunhal ou documental que comprovem tais versões.

A quantidade de entorpecentes, bem como sua variedade, além da quantia em dinheiro sem comprovação da sua licitude, comprovam a finalidade mercantil.

E mais, as versões dos policiais foram uníssonas acerca das circunstâncias do ocorrido, não havendo dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitiva, sendo de rigor a condenação dos acusados.

Destaque-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

Também não há que se falar em desclassificação para o crime do artigo 28 da lei de Drogas, já que a alegação de vício não tem o condão de operar a desclassificação para uso, pois como é sabido, normalmente encontram-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade. Assim, ainda que aleguem serem usuários, sendo certo que Vítor comprovou que já esteve internado para tratamento de dependência química, tal condição não afasta a prática do crime, pois comumente vendem para sustentar o próprio vício, não tendo o réu comprovado ter condições financeiras de adquirir tal droga para seu consumo.

Dessa forma, imperiosa, pois, a condenação dos réus pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Resolvido o mérito, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, para ambos os réus, e atendendo à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às consequências do crime, verifico que não há nenhuma circunstância judicial que justifique a elevação da pena, motivo pelo qual mantenho as penas no seu patamar mínimo, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, para ambos os réus, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem analisadas.

Na terceira fase, para ambos os réus, verifico como recomendável seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, principalmente porque essa causa de diminuição da pena subsume-se à situação dos acusados em questão (primários e não se vê a existência de antecedentes efetivos para justificar o impedimento dessa benesse, sem, também, qualquer demonstração de que se dediquem à atividade criminosa ou integrem organização criminosa), motivo pelo qual eles fazem jus à redução de 2/3. Assim, estabeleço a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, tornando-a definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, anteriormente, ao tratar de casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, sempre entendi, em atenção ao disposto no art. 5º, XLIII, da CF, a integral aplicação dos rigores da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), a qual determina a imposição do regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, com redação dada pela Lei nº 11.464/07), e da Lei nº 11.343/06, que veda a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, caput).

No entanto, ressalvada minha convicção pessoal, é necessário levar em consideração que, no âmbito dos Tribunais Superiores, em relação ao tráfico privilegiado, a

Jurisprudência se consolidou para diferenciá-lo do tráfico em sua forma fundamental, tratando-o como delito não assemelhado a hediondo, sempre que preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Nessa ordem de ideias, o Plenário do E. STF, ao julgar o HC nº 118.533/MS, em 23/06/2016, decidiu que: "O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos". Em vista deste precedente, a 3ª Seção do C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por unanimidade acolheu a tese vitoriosa no STF, revisando o entendimento até então firmado com o enunciado nº 512 daquela Corte, atualmente cancelado (Pet nº 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Importante destacar, em tempo, as decisões do E. STF que em caráter incidental declararam inconstitucionais, por afrontarem a individualização da pena, tanto a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (HC nº 111.840/ES, j. 27/06/2012), quanto a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos da Lei de Drogas (HC nº 97.256/RS, j. 01/09/2010), com a consequente promulgação da Resolução nº 5 de 2012 pelo Senado Federal, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Embora proferidas em processos individuais, sem eficácia vinculante, essas decisões da Corte Suprema devem ser observadas, em nome da segurança jurídica e na busca da uniformidade na resolução de conflitos.

Sob essas premissas, passo a analisar o caso dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às condições pessoais dos infratores e das circunstâncias específicas do comércio ilícito por eles desenvolvidos, afastada a hediondez do delito e suas consequências.

O presente caso, enfim, versa sobre a apreensão de drogas, que nos termos do laudo pericial pesavam aproximadamente 14 gramas no total, na posse de indivíduos primários, sem provas de conexão com as organizações criminosas ou traficância habitual.

Consequentemente, revendo posicionamento anterior e cedendo à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Ainda, porque presentes os requisitos correlatos, em atenção ao quantum de pena e a primariedade dos réus, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2º, parte final, do CP.

A primeira consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, indicando o Juízo das Execuções tanto o destinatário como a espécie de serviço a ser prestado pelo tempo da pena substituída; a segunda em prestação pecuniária no valor de 02 salários-mínimos na época do fato em favor de entidade pública ou privada, com destinação social, também a ser designada pelo Juízo das Execuções. Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra JEAN ROBERTO DE SOUZA e VITOR MOREIRA DE LIMA, para, com base no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, CONDENÁ-LOS à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, substituída nos termos acima deliberados.

Em razão da natureza da pena imposta, poderão os réus recorrer em liberdade.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Comprovado que o dinheiro apreendido era produto do narcotráfico, decreto seu perdimento em favor da União.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 28 de setembro de 2022.

Simone Rodrigues Valle

Juíza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA